

1500400-38.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO MARTINES CHIADO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... encontradas anotações da contabilidade do tráfico, que vinha sendo realizado por ele; e pela esposa também estaria praticando o tráfico. Por meio do telefone dela, viram que ela agia no tráfico com o acusado. Na informação nº 128, entendeu caracterizado o envolvimento de todos os réus; Edson faria intermediação de vendas. Tauana afirmou que Luiz utilizava sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500400-38.2022.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500400-38.2022.8.26.0302 - Controle 2022/000552

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MESSA e outros

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2071568/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23614080 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2071568 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO MARTINES CHIADO

Vistos.

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MESSA, TAUANA CRISTINA CARDOSO e EDSON BRUCKNER, qualificados, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, do Código Penal, porque, em período não precisado até o dia 15 de março de 2022, na Rua José Contador Júnior, nº 351, no Jardim Pedro Ometto, nesta cidade e Comarca, teriam se associado, de maneira estável e duradoura, para praticar, de forma reiterada, o tráfico ilícito de drogas. Ainda, LUIZ HENRIQUE e TAUNA CRISTINA foram denunciados e estão sendo processos como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 15 de março de 2022, por volta das 10h30min, na residência localizada na Rua José Contador Júnior, nº 351, no Jardim Pedro Ometto, nesta cidade e comarca, guardavam e tinham em depósito, 16,41

gramas da droga conhecida como cocaína e 25,23 gramas da droga conhecida como 'crack', derivada da cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificados (fls. 235/237), os réus apresentaram defesas prévias distintas (fls. 248, 251/253 e 258/259).

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2022 (fls. 260/263).

Os réus foram citados (fls. 319, 325 e 330).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

Encerrada a instrução criminal, em debates, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação dos acusados TAUANA e LUIZ nos termos da denúncia e a absolvição do acusado EDSO, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

A defesa de LUIZ, em debates, pugnou pela absolvição do réu no crime previsto pelo artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como teceu considerações acerca da dosimetria e regime a serem aplicados.

A defesa de EDSO, em alegações finais (fls. 370/374), pugnou pela absolvição do acusado pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, teceu considerações acerca da aplicação da pena.

Por fim, a defesa de TAUANA, em alegações finais (fls. 378/384), pugnou pela absolvição da acusada nos crimes que lhes foram imputados, ante a ausência de provas autorizadoras para o édito condenatório. Subsidiariamente, teceu considerações acerca da dosimetria e regime a serem aplicados.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos restou demonstrada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante de fls. 03/09, do Boletim de Ocorrência de fls. 17/20, do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23, do Auto de Constatação Provisório de fl. 24, dos documentos de fls. 55/64, das fotografias de fls. 69/70, da informação nº 81/2022 às fls. 74/75, da informação nº 128/2022 às fls. 147/166, do comprovante de depósito de fl. 167, do laudo definitivo de fls. 184/190, do laudo pericial de fls. 191/195 e 196/199, bem como dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria procede em parte.

A testemunha Policial Civil Paulo afirmou que realizaram investigação em relação a Luiz e Tauana. Receberam informação de que o réu Luiz estaria praticando o tráfico, noticiando que ele se dirigia a um bar, com a esposa dele (acredita que seja Tauana), e realizavam o tráfico. Foi localizado o endereço dele, solicitado mandado de busca e deferido. Na data dos fatos, dirigiram-se até a casa e, quando da diligência, os réus Luiz e Tauana estavam dormindo. No quarto deles foram localizados os entorpecentes (29 porções de cocaína, além de crack, em uma pedra bruta, mas um pouco fracionada). O dinheiro apreendido estava com Luiz. Foram encontradas anotações da contabilidade do tráfico, que vinha sendo realizado por ele; e pela esposa também estaria praticando o tráfico. Por meio do telefone dela, viram que ela agia no tráfico com o acusado. Na informação nº 128, entendeu caracterizado o envolvimento de todos os réus; Edson fazia intermediação de vendas. Tauana afirmou que Luiz utilizava sua máquina de cartão e celular para realizar venda de drogas. Antes dos fatos, também recebeu informação de informantes do envolvimento de Tauana no tráfico. Realizou várias diligências no local dos fatos, embora não tenha visto tanta movimentação em período diurno; a vizinhança falou que a movimentação era suspeita de tráfico.

No mesmo sentido foram os dizeres da testemunha Policial Civil Bruno. Confirmou que as informações formais e informais adrede às diligências descriam condutas perpetradas por Luiz e Tauana. Quando do cumprimento do mandado, Luiz admitiu que as anotações eram do tráfico. Disse que realizou algumas diligências antes do mandado de busca, como passar em frente ao local, parar na esquina e aguardar um pouco; é um trabalho de investigação. Não viram a comercialização de droga em si quando das diligências.

A testemunha Silvana afirmou que conhece Edson há cerca de 03 anos; trabalham juntos e não tem ciência de nada que o desabone.

A testemunha Paulo César, pai de Tauana, disse que residiu 15 dias com ela e Luiz, após separar-se de sua esposa. Não viu qualquer movimentação de pessoas relacionada ao tráfico.

A testemunha Paulo Vinicius Cardoso, irmão de Tauana, afirmou desconhecer os fatos imputados à sua irmã. Disse que frequentava a casa da acusada, que Tauana e Luiz se relacionavam há bastante tempo e que nunca presenciou pessoas estranhas indo à residência do casal.

A testemunha Ângela Maria Bruckner, irmã do acusado Edson, disse que seu irmão é usuário de drogas. Acredita que seja da droga cocaína. Disse que seu irmão trabalha na indústria de calçados, que possui registro em carteira. Afirmou que não reside com o acusado, mas que este mora perto de sua residência. Não tem conhecimento de que o acusado receba pessoas estranhas em seu domicílio ou que pratique o tráfico de drogas. Edson nunca foi preso.

Interrogada, a acusada TAUANA disse que possui união estável com o acusado Luiz, possuindo três filhos dessa união. Que trabalha como autônoma. Esclareceu que sua relação com Luiz dura há 14 anos. Que seu esposo trabalhava numa fábrica de calçados, mas que havia sido mandado embora. Que a droga apreendida pela polícia foi localizada sobre a cômoda do quarto do casal. Que Luiz tinha levado a droga havia uns 3 dias. Disse já ter alertado Luiz para parar com a traficância, mas não foi atendida pelo acusado. Que ele estava desesperado por conta dos filhos menores e pelo desemprego.

Interrogado, o acusado LUIZ, confessou a prática do crime de tráfico. Disse que era ele quem guardava a droga, que Tauana não auxiliava no tráfico. Que falava pra ela sobre essa conduta, mas que ela não compactuava com a prática. Que estava desesperado porque tinha crianças pequenas e dívida de drogas. Que naquele único dia (quando da revista policial) teria deixado a droga em sua casa. Afirmou conhecer Edson, que trabalhavam juntos na fábrica de calçados e que vendia drogas para ele. Que já comentou com Tauana, por telefone, sobre o tráfico que praticava. Que conversava com Edson, por telefone, porque era o fornecedor dele. Que Edson adquiria do depoente cocaína para consumo. Conhecia Edson há uns 9 meses antes de ser preso.

Interrogado, o acusado EDSON disse que a relação com os acusados era de amizade, que não praticou o tráfico com eles. Disse que tinha ciência de que Luiz traficava, tanto que comprava do coacusado cocaína. Utilizava cerca de uns 500 reais por mês. Esclarece que sempre trabalhou de forma lícita, nunca ficou parado. Continua trabalhando na fábrica de calçados. Nunca respondeu por nenhum processo criminal. Não sabia do envolvimento de Tauana na traficância. Que nunca cobrou ninguém para Luiz. Que Luiz chegou a pedir para que realizasse a cobrança de pessoas que trabalhavam com eles na fábrica, mas que não fez isso. Que nunca recebeu dinheiro de Luiz para realizar qualquer atividade.

No mérito, pelas provas amealhadas, verifico ser o caso de parcial procedência da ação penal, pois o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária, em parte, acerca da autoria e materialidade dos fatos imputados.

Conforme a informação nº 81/22 de fls. 74/75, a investigação policial iniciou-se em março de 2022, após a formalização de denúncia indicando que os acusados LUIZ e TAUANA estariam mantendo e realizando intenso tráfico em sua residência, na Rua José Contador Junior, nº 351 - Jardim Pedro Ometto, o que teria sido confirmado por sua vizinhança.

Ante o exposto, fora deferida a representação por mandado de busca domiciliar para apuração da prática delituosa imputada aos acusados (fls. 71/73), fato que desencadeou a prisão em flagrante do réu LUIZ, ante a apreensão de 29 (vinte e nove) porções de cocaína e 3 (três) porções de 'crack', em seu domicílio, além de uma balança de precisão, uma máquina de cartão, anotações indicativas da comercialização ilícita, invólucros plásticos para acondicionamento de drogas e a quantia de R\$ 405,00 em notas variadas (fls. 22/23 e 69). Nas mesmas circunstâncias, apreendido um aparelho telefônico, cujo conteúdo dirimiu qualquer dúvida quanto a coautoria da acusada TAUANA na prática do crime de tráfico de

drogas, bem como elucidou a existência da associação, estável e duradoura entre o casal, para a prática reiterada da traficância. Conforme restou apurado, as drogas encontradas na residência de LUIZ e TAUANA estavam dentro do quarto do casal, em local de fácil acesso à ambos. Quando inquirido na fase extrajudicial, o acusado LUIZ foi categórico ao confessar a prática do crime pelo qual está sendo processado, justificando sua conduta por estar desempregado e possuir uma elevada dívida de drogas, razão pela qual teria retomado o caminho do tráfico (fl. 16), versão esta por ele reiterada em juízo. E, em que pese a afirmação do acusado de que a ré TAUANA não estaria envolvida com a traficância, sua assertiva foi afastada pelas declarações prestadas por sua esposa, também acusada neste processo, e pelas mensagens degravadas do aparelho celular apreendido na ação policial. Inquirida (fls. 13/14), TAUANA admitiu possuir conhecimento do tráfico praticado em seu domicílio, tendo, inclusive, auxiliado LUIZ na percepção dos frutos do odioso comércio, o qual, segundo ela relatou, perdurou por quase 2 anos. O relatório nº 128/2022 às fls. 147/166 constatou a existência de diversas mensagens de texto e áudio que corroboram a prática do tráfico e a configuração da associação criminosa que ora se imputa aos acusados LUIZ e TAUANA. As conversas e áudios de fls. 148/149, trocados entre o casal, são claros ao constatar a traficância por eles empreendida, in litteris:

08/02/22 - 13h05 (0:11s) - LUIZ: "Então daqui pra frente cê vai ver só como é que vai ser... depois cê não vem falar... porque aquele dia ela veio pedir vinte real fiado e eu não ia vender, cê ficou me enxuzando... tá? Pa soltar... daqui pra frente cê vai ver como que vai ser... (fl. 148)

08/02/22 - 13h27 (0:35s) - TAUANA: Fiquei te enxuzando não, meu bonitinho... foi ela quer vinte reais... cê olhou na minha cara... nossa... mas... é fiado. Ai falei: é... você que sabe... vai lá e pega... então, você não falar.. você fala as coisas, e depois muda... tá vendo como você é falso... falei é assim não, filho... tudo pra você é tudo eu que faço, tudo eu que falo, é eu que faço, você não faz nada, você é santo... é, mas ela é bunduda né? Que nem falaram pra você, você confirmou que ela é bunduda. (fl. 149)

Em outro momento (11/02/2022), a acusada TAUANE avisa ao acusado LUIZ que teria convencionado com terceiro a forma do pagamento das drogas por eles fornecidas:

11/02/22 - 19h28 (0:21s) - TAUANA: "Né? E sobre o negócio lá... o cara falou que vai pegar a vista hoje... porque falei pra ele que a situação nossa tá feia... Aí ele falou: não, eu compro a vista, pra não ficar apertando ocês... falei: é... né? melhor... aí já tô subindo já... tô aqui na estação de luz, pá subir já..." (fl. 150 - grifos nossos).

Ainda, no dia 27/02/2022 (fl. 152), o diálogo havido entre TAUANA e terceiro (interlocutor "Pamela Tata") evidencia a total ciência da acusada sobre o tráfico ocorrido em sua residência, bem como o modus operandi para a desenvoltura do ilícito (anotação das dívidas do comércio ilegal em caderneta específica para este fim, conforme confessado por Luiz à fl. 16 - documento de fls. 55/64):

27/02/22 - 13h34 (0:22s) - TAUANA: "Ontem sua irmã veio aqui pegar o negócio, perguntou: "a PAMELA tá deveno muito?" Falei: "não sei"... "cê vende aí e não sabe?"... Falei: "Fia, quem marca é o LUIZINHO no caderninho, eu não fico olhando o caderno... Eu nem sei"... "ag Cês tem que saber, cê tem saber.. [ininteligível]"... Eu não..." (fl. 152 - grifos nossos)

E mais, verificou-se pelo aplicativo "Messenger" do facebook, que em 21/10/2021, a acusada TAUANA travou negociações para a cobrança de entorpecentes com o interlocutor "Marcelo Augusto", vulgo "Japa" (fls. 162/163), questionando-o sobre a

“moeda que ficou”, fazendo alusão de débitos em aberto da aquisição de entorpecentes.

Tais mensagens, quando confrontadas com as anotações contábeis apreendidas na diligência policial (fls. 55/64), apontam para a coincidência de nomes e apelidos ali contidos, demonstrando que, além de LUIZ, TAUANA estava a par de todo o comércio ilegal travado em sua residência, dele participando ativamente mediante a venda e cobranças das mercadorias ilícitas.

Por todo o exposto, as mensagens analisadas devem ser consideradas em conjunto com os depoimentos e diligências policiais, sendo tais elementos suficientes para formar um sólido conjunto probatório. Notadamente, as palavras dos policiais responsáveis pelo caso são no sentido de que os réus estariam há meses associados para prática do crime de tráfico de drogas, com divisões de tarefas e ajuda mútua na cobrança de débitos de terceiros não identificados.

Nesse sentido, os dizeres das autoridades responsáveis pelas investigações são categóricos em afirmar a consumação dos delitos.

Não há motivo para se duvidar da versão apresentada pelos policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 – grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

A localização dos entorpecentes, além da forma de acondicionamento em que os entorpecentes foram encontrados, bem como os demais objetos apreendidos com a droga, conforme fotografias de fls. 69/70, indicam que os réus LUIZ e TAUANA praticavam o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”.

Para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)".

Em relação aos entorpecentes apreendidos, tanto o auto de constatação preliminar (fl. 24), como o laudo definitivo (184/190) concluíram que os entorpecentes localizados na residência dos acusados correspondiam a 16,41g (dezesesseis gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína (fl. 185) e 25,23g (vinte e cinco gramas e vinte e três centigramas) da droga conhecida como 'crack', derivada da cocaína (fl. 187), salientando-se que estavam divididos em porções para a pronta-entrega (fl. 69).

Frise-se que também foram apreendidos objetos comumente utilizados no tráfico de drogas, como é o caso da balança de precisão contendo resquícios de cocaína (fls. 192 e 194), diversas embalagens de entorpecentes (fl. 199), além das anotações contábeis da traficância praticada pelos réus (fls. 55/64) e considerável quantia (R\$ 405,00), em notas variadas (fl. 69).

Oportuno ressaltar que a situação fática aqui demonstrada não se trata de simples coautoria ou de mera cooperação eventual, haja vista que as provas colhidas demonstram que a associação entre os acusados LUIZ e TAUANA perdurou por período razoável, não decorrendo de mera presunção pela condição de cônjuges que ostentam. Patente, pois, a demonstração da existência da associação criminosa, que em nada se assemelha à simples coautoria do crime de tráfico de drogas e, menos ainda, revela-se como efêmera e circunstancial unidade de vontades.

De mais a mais, segundo a melhor doutrina e pacífica jurisprudência, o que há de se distinguir, para afastar um agente do crime autônomo de associação e tê-lo apenas como mero corréu de um crime de tráfico é a efemeridade ou instabilidade do concurso de pessoas. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, a caracterização do crime de associação para o tráfico depende do dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 4ªed., rev., atual. e ampl. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016, p. 768).

Assim, infere-se dos autos as provas de estabilidade e permanência exigidas para a configuração desse delito quanto ao casal acusado. Logo, restou caracterizada a prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, durante as investigações, apurou-se que o réu EDSON BRUCKNER esteve associado com o casal LUIZ e TAUANE, auxiliando-os na cobrança de dívidas de drogas de outros devedores, o que foi por ele próprio admitido quando inquirido extrajudicialmente (fl. 178).

No entanto, em que pesem as mensagens de voz degravadas no relatório de fls. 147/166, as mensagens trocadas entre o acusado EDSON e TAUANA são datadas de 09 e 10 de março de 2022, inexistindo mensagens ou indícios em período diverso ou longínquo a demonstrar a estabilidade e permanência ínsitas ao tipo penal imputado ao acusado.

Isto, aliado à negativa do acusado de que estaria associado ao crime pelo qual está sendo processado, impõe sua absolvição.

A jurisprudência já se posicionou no sentido de que, para configuração do delito previsto pelo artigo 35 da lei 11.343/20066, mister que haja prova da efetiva associação para a traficância, não bastando que seja ocasional.

Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. I - Preliminar de nulidade pela ausência de realização de exame toxicológico afastada. II - Sentença mantida em relação ao tráfico. Materialidade e autoria comprovadas desse delito. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Tráfico privilegiado não reconhecido. Regime prisional mantido no fechado. III - Associação para o tráfico de drogas. Absolvição necessária, diante da ausência de provas da estabilidade, permanência e habitualidade, bem como o animus, que se traduz no prévio ajuste para a formação de um vínculo associativo

entre os envolvidos. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Criminal nº 1500984-57.2020.8.26.0567 - Salto de Pirapora - a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator: MARCOS CORREA), Julgamento 24/02/2021 - grifos não existentes no original).

"TÓXICO - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Concurso de pessoas - Prova cabal apenas de reunião dos denunciados para a traficância - Não se ficou sabendo, ao certo, de quantos negócios similares participaram os réus, um deles já falecido - Não caracterização do delito autônomo de associação previsto no artigo 14 da Lei 6.368/76, que não pode confundir-se com simples co-autoria - Aumento da pena prevista no artigo 18, inciso III, da referida lei, em grau máximo, em razão da periculosidade do apelado - Recurso provido." (Apelação Criminal n. 235.327-3 - Guaratingueta - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.09.98 - V.U.)

"REVISÃO CRIMINAL - Entorpecente - Tráfico - Concurso de pessoas - Reunião do peticionário com outras pessoas para a traficância apenas ocasional - Participação que se limitou a um único negócio - Não caracterização - de delito autônomo de associação e formação de quadrilha, prevista no artigo 14 da Lei 6.368/76, que não pode confundir-se com simples co-autoria - Aumento de pena, pela incidência do artigo 18, inciso III da Lei 6.368/76 - Revisão parcialmente acolhida." (Revisão Criminal n. 227.286-3 - São Paulo - 3º Grupo de Câmaras Criminais - Relator: Debatin Cardoso - 10.09.98 - M.V.) "ENTORPECENTE - Tráfico e Associação - Artigo 12 caput e 14 da Lei 6.368/76 - Descaracterização da associação prevista no artigo 14, por não comprovada a habitualidade - Reclassificação para o delito do artigo 18, inciso III, da referida Lei - Recursos parcialmente providos." (Apelação Criminal n. 230.120-3 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator: Oliveira Ribeiro - 03.03.98 - V.U.)

Embora a existência de indícios de que a associação do acusado EDSON com os réus LUIZ e TAUANE fosse habitual, tal fato não restou incontestado nos autos, até porque não foi produzida nenhuma prova que pudesse, efetivamente, corroborar com a descrição fática contida na denúncia. Também não foram descritas, de forma detalhada, atitudes vinculadas ao réu que pudessem confirmar o decreto condenatório com a certeza necessária. Aliás, testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram prova contundente que poderia ligar o acusado Edson aos demais acusados. A reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se enquadra ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Ausentes, então, os requisitos necessários para a caracterização do crime de associação, tal como ponderado pelo R. Parquet em debates. Nesse sentido, não havendo elementos seguros a indicar a associação para o tráfico ao acusado EDSON, inviável a condenação nessa parte, aplicando-se o "in dubio pro reo".

Diante do exposto, conclui-se que os elementos obtidos indicam que os réus TAUANA e LUIZ traficavam drogas e estavam associados de maneira estável e duradoura para tanto. No entanto, considerando a ausência de provas contundentes quanto a associação do réu EDSON, necessária sua absolvição, tal como solicitado pelo Ministério Público.

Passo à dosagem da pena.

PENA - LUIZ HENRIQUE

O réu é reincidente específico (fls. 84/85 - 700224810.2014/ 3001409-73.2013 - data fim execução prevista em 13/03/22) e possui maus antecedentes (fl. 85 - 7006414-85.2014 / 0000131-08.2008 - data do trânsito em julgado para a defesa em 31/10/2013) (fl. 84 - 7000615-91.2007 / 16318/2006 - trânsito em julgado para a defesa em 24/07/2007). Atento a essa circunstância e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena acima do mínimo legal, considerando a variedade e nocividade dos entorpecentes comercializados (cocaína e 'crack'), bem como os maus antecedentes que ostenta, que serão considerados nesta etapa. Por essa razão, fixo a segregativa: a) 7 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 714 dias-multa, para o crime previsto no artigo 33,

caput, da lei nº 11.343/06; b) 4 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e 1000 dias-multa, para o crime previsto no artigo 35, caput, da lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP - fls. 84/85) e a atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, alínea "d", do CP), de modo que realize a compensação das circunstâncias, mantendo as penas nos patamares anteriormente fixados.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em razão do acusado ser reincidente específico e ser aqui condenado pela associação para o tráfico, que evidencia a dedicação à atividade criminosa, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Ausentes outras causas, torno definitiva a pena conforme fixada.

Considerando a existência de concurso material entre as infrações, as penas deverão ser somadas, nos termos do artigo 69, "caput", do Código Penal, perfazendo o total de: 11 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão e 1714 dias-multa.

PENA - TAUANA CRISTINA

A ré é primária e não ostenta antecedentes criminais (fl. 276). Atento a essa circunstância e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena acima do mínimo legal, considerando a variedade e nocividade dos entorpecentes comercializados (cocaína e 'crack'), o que corresponde à: a) 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa, para o crime previsto no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 e; b) 3 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 900 dias-multa, para o crime previsto no artigo 35, caput, da lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas. Deixo de aplicar a atenuante relativa a confissão, vez que a versão apresentada pela acusada a eximia dos crimes que lhe foram imputados, tendo sua responsabilidade sido aclarada mediante o relatório nº 128/2022.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em razão da condenação pela associação para o tráfico, que evidencia a dedicação à atividade criminosa, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Ausentes outras causas, torno definitiva a pena conforme fixada.

Considerando a existência de concurso material entre as infrações, as penas deverão ser somadas, nos termos do artigo 69, "caput", do Código Penal, perfazendo o total de: 10 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e 1542 dias-multa.

O dia multa aplicado aos réus deverá ser calculado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira dos acusados.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos ou a aplicação do "sursis", em razão do disposto no artigo 44, inciso I, e do artigo 77, "caput", ambos do Código Penal, considerando a quantidade da pena aplicada aos acusados. Fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, a teor dos artigos 33, §2º, "a" e §3º, e 59, ambos do Código Penal, considerando a duração da associação entre os réus e da variedade e nocividade de drogas por eles movimentadas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda penal para CONDENAR:

a) LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MESSA, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de: 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 1714 (mil, setecentos e catorze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal;

b) TAUANA CRISTINA CARDOSO, qualificada nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 1542 (mil, quinhentos e quarenta e dois) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Bem como para ABSOLVER o réu EDSON BRUCKNER, qualificado nos autos, da imputação contida na exordial, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Deixo de reconhecer o direito de recorrer em liberdade ao acusado LUIZ, pois nada de novo ocorreu de modo a subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque responderam presos ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-los em liberdade exatamente depois de receberem a sentença penal condenatória. Em casos tais, também assim se posiciona o STJ: [...]. 4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] - (STJ - HC 596.260/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020 - destaquei).

Não estando presa por este processo, não imponho o imediato cumprimento da pena à ré TAUANE.

Decreto o perdimento dos objetos e numerário apreendidos (fls. 22/23 e 167) em favor, da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, uma vez que produtos ou instrumentos do delito de tráfico, considerando, ainda, a condenação, o modo e o local em que foram localizados.

Custas pelos acusados, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Jaú, 18 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA